

1508273-94.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... policiais lhe informaram que estava sendo preso por tráfico de droga, mas não apresentaram droga e, depois de muito tempo, abordaram um veículo Gol prata e os policiais disseram que o rapaz também estava "passando" droga, sendo que na delegacia foram apresentados. Negou que estava envolvido com o tráfico e declarou que estava com tornozeleira eletrônica. Informou que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508273-94.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508273-94.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI ESTEVES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI

Vistos.

DAVI ESTEVES e ANDERSON SOARES FARIA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006, obedecidas as disposições da Lei nº 8072/90 (equiparado a hediondo), por que no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 08h30min, na Rodovia SP 458/294, nesta cidade de Marília, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportaram, guardavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 1 invólucro plástico contendo 40,38 gramas (massa líquida) de cocaína; 69 invólucros plásticos contendo 190,37 gramas (massa líquida) de cannabis sativa L, que contém tetrahydrocannabinol; 140 microtubos plásticos, contendo 74,2 gramas de cocaína; 1 invólucro plástico contendo 51,59 gramas (massa líquida) de cannabis sativa L, que contém tetrahydrocannabinol; 55 invólucros plásticos, contendo 160,27 gramas (massa líquida) de cannabis sativa L, que contém tetrahydrocannabinol; 1 seguimento plástico branco, contendo 40,1 gramas de cannabis sativa L, que contém tetrahydrocannabinol.

Segundo a denúncia, nas mesmas condições de tempo e local acima e em período anterior, cuja extensão não foi possível ainda apurar, os acusados associaram-se ao

tráfico de entorpecentes,

Consta, ainda, que no dia dos fatos, policiais militares estavam em rotineiro patrulhamento, quando avistaram no acostamento da Rodovia SP 294, dois ônibus estacionados, além do veículo VW/Gol, placas ETK4G06, de cor prata. O acusado Anderson foi visto pela guarnição entregando uma sacola para o acusado Davi, que estava no interior do ônibus. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, Anderson assumiu a direção do veículo e fugiu, enquanto Davi arremessou aludida sacola pela janela do ônibus.

O veículo VW/Gol, conduzido por Anderson, foi localizado no Distrito de Padre Nóbrega e, em seu interior, foram localizadas 01 porção de cocaína, 01 porção fragmentada de maconha, 69 porções de maconha e 140 pinos de cocaína. Tal acusado estava em poder de dois aparelhos celulares, além da quantia de R\$ 51,00.

Suspensa temporariamente a audiência de custódia, de acordo com recomendações da Egrégia Corregedoria bandeirante, conforme Provimento CSM n.º 2.545/2020, bem como o artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, em razão da pandemia da Covid-19, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva dos acusados.

Em data de 21/09/2021 foi impetrado pedido de Habeas Corpus em favor do acusado Anderson, tendo sido a liminar indeferida em 23/09/2021, consoante se verifica de fls. 136/149.

Foi apresentada em favor dos réus a defesa prévia a que alude o art. 55 da Lei 11.314/06 (fls. 186/197 e fls. 290/292), o Ministério Público manifestou-se a fls. 277 e fls. 295, e a denúncia foi recebida em 11/02/2022 (fls. 297/300). Durante audiência de instrução, debates e julgamentos, realizada em 21/03/2022, foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogados os réus (fls. 333/334).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 357/369), postulando pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia, visto que comprovada a materialidade e incontestada a autoria. No tocante à dosimetria da pena, assevera que na primeira fase a pena deverá ser afastada do piso para ambos os réus, em razão de um dos entorpecentes encontrados possuir natureza química geradora de maior grau de dependência. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante de reincidência em relação ao réu Davi. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena. Pontua não cabível a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes e a associação de tráfico praticada pelos corréus. Requer, sejam somadas as penas em razão da prática de crimes distintos e a fixação de regime inicial fechado, mormente em relação ao réu Davi.

A defesa técnica do acusado Anderson, apresentou alegações finais (fls. 372/402) pleiteando a improcedência da ação. Alega que deve ser afastado o crime de associação ao tráfico, eis que os agentes não se conheciam, logo, sustenta não existir uma associação estável e duradoura. Requer, assim, a absolvição nos termos do artigo 386, VII, parágrafo único e incisos I e II, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, requer que seja o acusado condenado a pena prevista para o delito de tráfico privilegiado.

A defesa técnica do acusado Davi, apresentou alegações finais (407/412) requerendo que seja julgada improcedente a ação penal com a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, subsidiariamente, em caso de condenação requer aplicação de penas mínimas e fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 24/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28/30), imagens fotográficas (fls. 40/53), pela constatação da natureza entorpecente do produto apreendido (fls. 33/37) e exame químico-toxicológico (fls. 160/167), conclusivos para cocaína e maconha, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos, mas apenas em relação ao delito de tráfico de drogas.

A testemunha Eduardo Ibara Kobayashi, policial militar, em depoimento em sede policial (fls. 06), declarou que estava em patrulhamento pela Rodovia SP 294 quando avistou dois ônibus estacionados no acostamento e um veículo VW/Gol, placas ETK4G06, de cor prata, também estacionado. Narrou que, de longe, avistou que o condutor do veículo, posteriormente identificado como Anderson, entregou para um outro indivíduo, que estava no interior do ônibus de camiseta vermelha, uma sacola plástica. Afirmou que Anderson, ao avistar a viatura da Polícia Militar se aproximando, rapidamente adentrou no veículo e saiu do local, ao passo que o indivíduo que estava no interior do ônibus, posteriormente identificado como Davi, arremessou a sacola pela janela, para o lado da rodovia. Esclarece que Davi foi abordado e no momento confessou que na sacola havia maconha. Ato contínuo, o depoente verificou a sacola e em seu interior localizou 01 porção fragmentada, além de 55 porções de maconha. Afirmou que o veículo VW/Gol foi localizado no Distrito de Padre Nóbrega de Marília, sendo que em seu interior foram encontrados 01 porção de cocaína, 01 porção de maconha fragmentada, além de 69 porções de maconha e 140 pinos de cocaína. Disse que dois celulares também foram localizados em posse de Anderson, os quais foram devidamente apreendidos, assim como o veículo, bem como que com Anderson também foi localizada a quantia de R\$ 51,00 e com Davi a quantia de R\$ 50,00, valores igualmente apreendidos.

Em Juízo, ratificou o depoimento prestado em sede de inquérito policial. Acrescentou que o acusado Davi disse que a droga seria para ele mesmo e que ele mesmo havia arremessado a droga. Narrou, ainda, que localizaram o acusado Anderson no Distrito de Padre Nóbrega, na Rua 07 de Setembro, e que este admitiu que somente havia a droga que estava no carro e a que entregou para Davi. Esclareceu que não foi falado qual a relação entre os dois acusados, bem como não os conhecia. Respondendo à acusação, afirmou que não participou da busca realizada no veículo, mas viu a droga ali localizada, sendo que ambas as drogas eram semelhantes e não se recorda de algum outro objeto ter sido apreendido além das drogas. Em resposta aos questionamentos da defesa, declarou que no interior do ônibus havia somente o acusado Davi de camiseta vermelha, os outros todos estavam de branco e não havia ninguém de camiseta rosa ou semelhante. Informou que Davi retornou para dentro do ônibus e somente depois arremessou a sacola, sendo que somente Anderson foi em direção ao veículo Gol. Disse, ainda, que primeiro foram atrás de Davi e somente depois foram em busca de Anderson, que não sabe quanto tempo se passou até encontrarem o acusado Anderson e quando o encontram não havia policiais e nem populares no local. Narrou que não acompanhou o depoimento dos presos e nem viu o delegado ouvindo os acusados. Informa, por fim, que a droga encontrada no veículo estava armazenada toda dentro de uma sacola e a confissão de Davi se deu ainda no ônibus, assim como na delegacia.

A testemunha Elton Sales, policial militar, em seu depoimento em sede policial (fls. 07), declarou que diligenciou na presente ocorrência, em que os acusados Anderson e Davi foram surpreendidos na posse de um total de 01 porção de cocaína, 02 porções fragmentadas de maconha, 124 porções de maconha e 140 pinos de cocaína, além de 02 celulares e um total de R\$ 101,00 em dinheiro e um veículo VW/Gol,

placas ETK4G06, que estavam utilizando para o transporte da droga. Narrou que, pelas circunstâncias da abordagem, além da quantidade, diversidade e maneira de embalagem das substâncias, ou seja, tipicamente para a venda, ficou evidenciado que o destino da droga seria para o ilícito comércio e que o dinheiro, celulares e veículo estavam diretamente relacionados com a traficância e que ambos os acusados estavam agindo previamente associados ao tráfico de drogas. Esclareceu que, em patrulhamento pela Rodovia SP 294, foram avistados dois ônibus estacionados no acostamento e o veículo supracitado, do acusado Anderson, ocasião em que este entregava para o acusado Davi, que estava no interior do ônibus, uma sacola plástica. Relatou que, ao avistar a viatura da Polícia Militar se aproximando, Anderson rapidamente adentrou no veículo e saiu do local, enquanto Davi arremessou a sacola pela janela, para o lado da rodovia. Ao ser abordado, Davi confessou que na sacola havia maconha, sendo que no interior desta foi localizada 01 porção fragmentada, além de 55 porções de maconha. O veículo VW/Gol foi localizado no Distrito de Padre Nóbrega e em seu interior foi localizada 01 porção de cocaína, 01 porção de maconha fragmentada, além de 69 porções de maconha e 140 pinos de cocaína, bem como foram encontrados, ainda, dois celulares na posse de Anderson, além da quantia de R\$ 51,00 e, com Davi, a quantia de R\$ 50,00.

Em Juízo, ratificou seu depoimento tomando na seara policial. Respondendo às perguntas da acusação, acrescentou que o ônibus era de detentos de saída temporária e não houve diálogo com o motorista do ônibus. Reconheceu os acusados, distinguindo quem estava dentro do ônibus e quem estava dirigindo o veículo Gol, esclarecendo que não os conhecia até a data dos fatos. Narrou que o acusado que estava dentro do ônibus confessou que o entorpecente era seu e, em relação ao acusado que dirigia o veículo Gol, informou não se recordar dele ter assumido como seu os entorpecentes. Disse que, junto com outros policiais que chegaram para apoiar a ação, fez a busca no veículo Gol, sendo que os entorpecentes estavam no banco de trás do carro, mas não se recorda precisamente disso e também não se lembra de nenhuma semelhança na embalagem das drogas encontradas na rodovia e no automóvel. Respondendo à defesa, disse que no interior do ônibus havia mais detentos, mas de camiseta branca e não vermelha, que Davi confessou que havia dispensado a sacola pela janela do ônibus, bem como que não sabia precisar quanto tempo após a abordagem Davi ocorreu a abordagem de Anderson. Informou ainda que a abordagem no carro foi feita sem a presença de terceiros, visto que quem acompanha a fiscalização é o próprio condutor, e a sacola que foi atirada pela janela do ônibus foi recolhida pelo próprio declarante, sendo que as drogas estavam embaladas em uma sacola verde e outra parte em uma fita preta.

O réu Anderson Soares Faria, interrogado em solo policial (fls. 09), reservou-se do direito de permanecer calado.

Em Juízo, informou que, na data dos fatos, acordou cedo e foi ao banco sacar o seu dinheiro, então, retornando pra sua casa, o seu carro fez um barulho estranho ao que parou na pista e viu que havia dois ônibus parados e uma sacola na pista. Ato contínuo, se aproximou da sacola os presos gritaram "não pega não que é nossa", momento em que ficou com medo, pois havia vários presidiários no ônibus, e, então, arremessou a sacola para um dos presos. Declarou que não havia viatura no local. Narrou que foi para sua casa, tendo antes parado em uma mercearia e quando saiu da mercearia viu que uma viatura o estava seguindo. Relatou que os policiais o pararam, apontaram a arma para o seu rosto e o levaram cerca de aproximadamente 10 metros do seu carro, deixando-o embaixo de uma árvore, onde fizeram a abordagem. Declarou que os policiais não deixaram nenhum popular perto da abordagem, tendo ficado um policial com o declarante e os outros dois foram fazer a revista no seu veículo, sendo que nada foi encontrado, mas, mesmo assim foi levado para delegacia. Afirmou que na delegacia queria conversar com sua família e com seu advogado, porém não conseguiu, bem como que foi entregue um papel para que ele assinasse e quando leu o papel viu escrito "droga, maconha, cocaína e dinheiro" e que, posteriormente, o seu advogado chegou. Declarou, ainda, que o objeto arremessado era uma sacola

branca, mas não chegou a ver o que tinha na sacola, que seu telefone estava no carro e foi apreendido junto com o celular que havia comprado para sua filha que não tinha nem chip, que o seu celular é um "J2 prime" Branco e o da sua filha é um "Gran Prime" escuro. A respeito da carteira de visitante expedida pela Secretaria da Administração Penitenciária apreendida, declarou que era sua, pois seu irmão, que se chama Alan, foi preso e alguns meses atrás foi visitá-lo apenas uma vez. Informou que no momento em que parou seu carro não havia viaturas no local, bem como quando saiu do local com seu carro não havia viaturas por perto. Negou que tenha desrespeitado os sinais dos policiais para que parasse o seu veículo. Afirmou, que não conhecia os policiais, que na delegacia não manifestou a sua vontade de ficar calado, bem como que não teve a oportunidade de conversar com o delegado e não conhecia o acusado Davi. Disse que só tinha R\$ 1,00 (um real) consigo, que havia saído para sacar o seu seguro-desemprego com R\$ 16,00 (Dezesseis reais), mas como comprou alguns refrigerantes na mercearia ficou com apenas R\$ 1,00 (um real). Afirmou que se quisesse fugir teria conseguido, pois viu os policiais vindo a mais de 200 metros na contramão. Afirmou que nenhum popular viu os policiais tirando droga de dentro do seu veículo, pois os militares não permitiram que nenhum popular visse a abordagem, esclarecendo que o carro é da sua irmã. Esclareceu que não há banco mais próximo de sua residência e, por isso, havia ido sacar o seu seguro-desemprego próximo ao supermercado Tauste Norte, no seu banco Bradesco. Declarou que foram fotografados na delegacia somente sem camisa, que ficaram algemados um do lado do outro e que Davi estava vestido com uma camiseta branca, calça e chinelo.

O réu Davi Esteves, na seara policial (fls. 08), reservou-se do direito de permanecer em silêncio.

Em Juízo (fls. 333/334), negou os fatos narrados. Informou que havia acabado de sair da colônia, e fazia 05 minutos que o ônibus estava indo sentido Capital (São Paulo), especificamente para Barra Funda, que estava sentado no último banco do ônibus e assim permaneceu quando o ônibus parou para ser abordado. Narrou que os policiais adentraram o ônibus, avisaram que era uma denúncia e ele estava sendo preso por tráfico de drogas. Disse que na delegacia foi dito a ele que um rapaz havia passado a droga, ao passo que respondeu que desconhecia tal fato, que queria dar o seu depoimento para ter audiência de custódia, mas foi impedido. Afirmou que assinou o B.O. recebendo tapas no peito e na cabeça, que não iria ficar apanhando, eis que está no sistema penitenciário há oito anos, teve duas tuberculoses e tem imunidade baixa. Negou que conheça o acusado Anderson. Informou que estava de saída temporária e havia 96 presos divididos em dois ônibus fretados, negou, ainda, que estava de camiseta vermelha, pois não é permitido o uso de camiseta de outra cor que não seja branca. Afirmou que os policiais não revistaram outros presos, sendo o declarante o único revistado e, após ser revistado, foi levado para viatura, onde os policiais lhe informaram que estava sendo preso por tráfico de droga, mas não apresentaram droga e, depois de muito tempo, abordaram um veículo Gol prata e os policiais disseram que o rapaz também estava "passando" droga, sendo que na delegacia foram apresentados. Negou que estava envolvido com o tráfico e declarou que estava com tornozeleira eletrônica. Informou que os policiais, quando da abordagem, não o chamando pelo nome, apenas disseram que o motivo da prisão era o tráfico, não explicaram como sabiam que ele era a pessoa da denúncia, que havia denúncia especificamente contra ele e que no ônibus havia mais homens com características semelhantes a suas. Declarou que estava indo para São Paulo e os ônibus costumam ter apenas uma parada quando está próximo a São Paulo e o veículo só parou por conta da abordagem policial. Esclareceu que não estava de moletom, apenas de camiseta branca, não foi fotografado com a camiseta vermelha, não levava nenhuma mochila dentro do ônibus e que não conhece Anderson.

Finda a instrução processual, tem-se que a negativa dos acusados quanto a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é frágil e inconsistente, sendo afastada pelo restante da prova produzida.

O acusado Anderson disse que transitava com o veículo no local dos fatos quando o carro fez um barulho estranho, motivo pelo qual parou na pista e viu que havia dois ônibus parados e uma sacola na pista, aproximou-se da sacola e os presos gritaram "não pega não que é nossa", momento em que ficou com medo, visto que havia vários presidiários nos ônibus, e, então, arremessou a sacola para um dos presos. Desconhece a droga e o dinheiro.

O acusado Davi declarou que estava de saída temporária e o ônibus estava indo sentido Capital (São Paulo), que estava sentado no último banco do ônibus e assim permaneceu quando o ônibus parou para ser abordado, afirmou que estava de camiseta branca e não vermelha, negou que conheça o acusado Anderson e que este não lhe entregou droga.

Tais negativas, contudo, foram frontalmente contrariadas pelos demais elementos de prova trazidos aos autos. As versões apresentadas pelos réus em Juízo restaram inverossímeis e isoladas nos autos, não encontrando qualquer respaldo nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que os acusados eram realmente proprietários da droga apreendida, eis que inegável que a droga foi apreendida com os acusados, conforme destacado, amoldando-se a conduta às figuras típicas dispostas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, mormente a de transportar e trazer consigo.

As circunstâncias em que foram flagrados, a forma como estava acondicionada a droga, bem como a diversidade de espécies, indicam a prática da atividade ilícita de tráfico.

Embora os acusados não tenham sido flagrados negociando a venda de drogas, as circunstâncias da prisão evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes, vez que os policiais narraram que os acusados foram abordados em posse de quantidade considerável de entorpecentes (01 invólucro plástico contendo 40,38 gramas de cocaína; 69 invólucros plásticos contendo 190,37 gramas de maconha; 140 microtubos plásticos, contendo 74,2 gramas de cocaína; 01 invólucro plástico contendo 51,59 gramas de maconha; 55 invólucros plásticos, contendo 160,27 gramas de maconha; 01 seguimento plástico branco, contendo 40,1 gramas de maconha), demonstrando que se destinaria a venda.

Assim, a quantidade de droga apreendida, a forma como estavam acondicionadas (separadas em pequenas porções), não deixam dúvidas de que se destinava à comercialização, o que configura o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Vale salientar que é irrelevante que não tenha efetivamente se consumado atos de comercialização, pois o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 também engloba a circunstância do agente trazer consigo, transportar e guardar substância entorpecente, desde que haja provas de que não eram para consumo pessoal (caso em que ter-se-ia o crime do art. 28 de referida lei), tal como ocorre no caso ora analisado.

Por outro lado, a materialidade está provada pelo exame químico-toxicológico, que concluiu serem cocaína e maconha as substâncias apreendidas (fls. 160/167).

Como se vê, as versões dos réus não se sustentam ante as provas constantes dos autos. Com efeito, as testemunhas policiais foram uníssonas e enfáticas em descreverem o ocorrido, demonstrando coerência e isenção de ânimos, merecendo, assim, todo o crédito.

As testemunhas Eduardo e Elton, inquiridas em Juízo, confirmaram a dinâmica dos fatos, qual seja, que avistaram o acusado Davi recebendo de Anderson e, posteriormente, arremessando o entorpecente pela janela do ônibus, o acusado Anderson evadindo-se rapidamente do local ao avistar a viatura policial, bem como que foram localizados entorpecentes no veículo conduzido pelo acusado Anderson.

Convém também observar que os depoimentos das testemunhas policiais, como tem reiteradamente se manifestado a jurisprudência, não podem ser desconsiderados pelo simples fato de serem policiais. Não havendo qualquer indício nos autos quanto à suspeição desses agentes públicos, estes depoimentos são aptos como meio de prova. O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/54).

Frise-se que pequenas divergências não invalidam os relatos, de modo que as defesas técnicas dos réus não lograram êxito em comprovar que Davi não estava de camiseta vermelha, ou ser exigência da SAP que os detentos deixem o sistema prisional em período de saídas temporárias trajando o uniforme composto de camiseta branca e calça caqui, sendo que à defesa incumbiria tal ônus, nos termos do art. 156, do CPP.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente os acusados, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia. Frise-se que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. E seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta de suas atividades.

A par disso, ficam eles igualmente sujeitos, como qualquer cidadão comum, às penas do crime de denúncia caluniosa e falso testemunho, caso venham a imputar falsamente a qualquer pessoa a prática de crimes ou a mentir em processo judicial, nos termos do art. 339 e 342, ambos do Código Penal.

Em que pesem os argumentos da Defesa, verifico que há provas da existência do crime, bem como da autoria, sendo estas suficientes para embasar o decreto condenatório no tocante ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao delito previsto no art. 35 da lei de drogas, não ficou devidamente caracterizado. Nos autos há prova de que os réus, na data dos fatos, estavam aliados na conduta de transportar e trazer consigo entorpecentes, porém inexistem notícias de que efetivamente estavam associados, de forma estável e permanente, para o comércio ilícito de drogas.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar e que haja um mínimo de estabilidade e organização nesta associação, não bastando a mera reunião de duas ou mais pessoas para a prática conjunta do tráfico.

Com efeito, entende-se que não restou seguramente comprovada a associação dos acusados para a prática criminosa. De fato, no caso sub judice, não restou comprovado que os acusados estivessem efetivamente associados para praticar, "reiteradamente ou não", o delito de tráfico de drogas, até mesmo porque a simples reunião esporádica é insuficiente para caracterizar a infração penal.

Da análise do conjunto probatório amalhado aos autos não se extrai, respeitado o entendimento do ilustre membro do Parquet, a participação estável dos acusados em grupo criminoso, atuando com estabilidade e estruturação, isto é, exercendo funções delimitadas com divisão de tarefas, depreendendo-se que, inobstante as circunstâncias do crime, tratou-se de fato isolado, à míngua de provas firmes e

seguras em sentido contrário.

Destarte, tem-se que a acusação, após a instrução processual, não logrou êxito em comprovar a presença de elementos suficientes à certeza de que estivessem os réus associados de forma estável com demais membros de eventual grupo, sendo possível concluir que eventualmente os acusados poderiam ter sido contratados para apenas uma empreitada criminosa e relativa aos fatos descritos na exordial acusatória, emergindo dúvidas razoáveis quanto à estabilidade e à habitualidade da colaboração com terceiros, resolvendo-se a questão, destarte, em seu favor.

Na hipótese versada não há provas cabais que demonstrem terem os acusados se associado com terceiros para praticar o crime de tráfico de drogas de maneira estável e permanente, a despeito da perícia realizada no aparelho celular apreendido com o réu Anderson (fls. 205/253), não restou comprovada a aliança entre os réus, visto não há como se concluir, sem sombra de dúvidas, que o interlocutor se trata do acusado Davi e que eles estariam associados com vistas ao tráfico de entorpecentes.

O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual).” (HC 139.942/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6.T., j. 19/11/2012, Informativo 509). (destaquei)

De rigor, portanto, a absolvição dos acusados em relação à imputação contida na peça acusatória, relativamente ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, passando-se à dosimetria da pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, em relação ao corréu ANDERSON SOARES FARIA, atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, observe que os policiais militares apreenderam drogas variadas, dentre as quais, cocaína, de maior poder vulnerante, que indica a maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual exaspera-se a pena base em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, permanecendo a pena tal como fixada.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem consideradas. O réu é primário e não há nos autos elementos que indiquem que ele se dedique a atividades criminosas ou participe de organização criminosa, razão pela qual deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A fração, contudo, em função da variedade de entorpecentes apreendida, de alto poder viciante e destrutivo, deve ser de 1/6, resultando em uma pena final de 5 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, fixa-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, suficiente à reprovação



da grave conduta do réu, que se viu envolvido no comércio ilegal de cocaína, droga de considerável potencial lesivo à saúde pública.

A conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena ao réu são incabíveis por falta de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo a que aludem os artigos 44, incisos I e III, e 77, ambos do Código Penal.

Relativamente ao corréu DAVI ESTEVES observando o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, considerando que os policiais militares apreenderam drogas variadas, dentre as quais, cocaína, de maior poder vulnerante, que indica a maior reprovabilidade da conduta, bem como que o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 00013688-31.2014.8.26.0554, trânsito em julgado em 01/03/2016 fls. 272), exaspera-se a pena base em 1/4, resultando em 06 (anos) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase incide a circunstância agravante da reincidência, consoante se extrai da folha de antecedentes anexada a fls. 271/272, uma vez que foi condenado, por sentença transitada antes do cometimento do delito ora imputado (processo n.º 0066971-21.2017.8.26.0050, da 11ª Vara Criminal Foro da Barra Funda, trânsito em julgado em 12/02/2019 - fls. 271), o que enseja a exasperação da pena na fração de 1/6, resultando na pena provisória de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, permanecendo a pena tal como fixada.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2.º, do Código Penal.

A conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena ao réu Davi são incabíveis ante a falta de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo a que mencionam os artigos 44, incisos I e III, e 77, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Pelas condições econômicas dos réus, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor fixado no mínimo legal.

Nego aos réus o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta praticada demonstra a necessidade de continuidade da custódia. Afinal, traziam consigo quantidade e diversidade de droga, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, podem buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

Os réus permaneceram presos durante todo o processo para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Assim é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes." (RHC n.º 117.802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.T., j.

10/06/2014, DJe 01/07/2014).

Destarte, não resta outra alternativa senão a parcial procedência da ação penal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: a) CONDENAR o réu ANDERSON SOARES FARIA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e o réu DAVI ESTEVES, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06; b) ABSOLVER os acusados ANDERSON SOARES FARIA e DAVI ESTEVES da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

Em face da condenação, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, letra "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intinem-se pessoalmente, para efetuar o recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando suspensa a exigibilidade caso sejam beneficiários da gratuidade da justiça.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução das penas impostas. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, do valor apreendido (R\$ 101,00), conforme auto de exibição/apreensão, por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro, dos aparelhos celulares, bem como do veículo VW/Gol 1.0, cor prata, placas ETK4G06 (fls. 28 e fls. 30), utilizados na prática do comércio espúrio, como consequência da condenação, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado.

Comunique-se a autoridade policial para que providencie a destruição da droga apreendida, contraprovas e eventuais embalagens, apetrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos termos do art. 72 da Lei n.º 11.343/06, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Marília, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA